

1500291-10.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... do veículo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão justificadas, pois de acordo com a lei: fundada suspeita (art. 244 do CPP). Policiais que apontaram de forma segura que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o acusado, que se encontrava sentado em uma guia num local conhecido como ponto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500291-10.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500291-10.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061586/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 23402719 - 04º D.P. AMERICANA, 467/22/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2061586 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ROBERVAL ALEXANDRE CLARO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ROBERVAL ALEXANDRE CLARO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; porque na data e locais descritos na denúncia, previamente conluiado e com unidade de propósitos com pelo menos outros 02 indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e privação de liberdade da vítima J.W.S., subtraíram para si coisas alheias móveis, 01 (um) veículo trator rodas "Pá Escavadeira" modelo

924K, marca "Caterpillar", e 01 (um) aparelho de telefone celular, pertencentes à empresa "DE PAULA".

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 (fls. 104/112).

O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 253/255).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 360/361, fls. 375/376 e fls. 419/420).

Em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 424/428), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se, o Doutor Defensor do réu (fls. 430/456) requereu a absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente a exclusão das qualificadoras, com fixação de pena mínima e regime mais brando.

Considerando as alegações de ilegalidade de busca e nulidade de reconhecimento, os autos retornaram ao Ministério Público, o qual manifestou-se as fls. 463/465.

É, em síntese, o relatório.
DECIDO.

Preliminarmente, em relação a alegada tortura, os fatos foram amplamente analisados durante o tramite processual, não se encontrando indícios veementes de sua ocorrência, conforme deliberação de fls. 244/249.

Ainda, não há que se reconhecer a preliminar e se falar em nulidade do reconhecimento na fase investigativa. Trata-se de eventual mera irregularidade, se por acaso o reconhecimento na polícia não tenha observado estritamente o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não causando qualquer prejuízo, muito menos nulidade. Nesse sentido:

Roubo Triplamente qualificado (emprego de arma concurso de agentes e restrição liberdade). Autoria demonstrada pela palavra das vítimas, que reconheceram o acusado com convicção. A inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP nos reconhecimentos policial e em juízo não os invalida só exigindo que na respectiva valoração dessas provas esse fato seja considerado pelo julgador. (...). (TJSP; Apelação Criminal com Revisão - 993.06.018116-5 - 0000416-48.2006.8.26.0069; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bastos - Vara Única; Data do Julgamento: 12/02/2009; Data de Registro: 01/04/2009)

Arguição de nulidade por falha no reconhecimento operado na delegacia e em juízo - Rejeição - Validade do ato ante o fato de que o artigo 226 do Código de Processo Penal traz em seu bojo apenas uma recomendação, desnecessária se a vítima, de pronto, reunir condições de levar a efeito a identificação do réu, caso dos autos. (...). Apelo do réu Maicon parcialmente provido, enquanto desprovido o do outro, rejeitada a preliminar. (TJSP; Apelação Criminal 0000512-86.2017.8.26.0551; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)

PRELIMINAR - Nulidade inexistente. Reconhecimento do réu pelas vítimas. Inobservância do quanto disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Inocorrência. Ademais, formalidades previstas no art. 226 do CPP, não se revelam essenciais, mas encerram mera recomendação. Matéria preliminar afastada. LATROCÍNIO TENTADO - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Condenações mantidas. PENAS e REGIME PRISIONAL - Corretamente impostos, não comportando modificação. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 0000991-11.2018.8.26.0530; Relator

(a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)

ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - (...). III - A jurisprudência tem apostado na validade do reconhecimento fotográfico do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja corroborado com outros elementos de prova, caso dos autos. IV - A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal/fotográfico do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo, pois a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível. V - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1144500, 20171010058690APR - 0005765-57.2017.8.07.0010, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: 157/173)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A inobservância do procedimento previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal gera, tão-somente, nulidade relativa, que, além de dever ser arguida no momento oportuno, exige a demonstração do efetivo prejuízo daí decorrente" (RHC n. 83.135/SE, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). 2. Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista. 3. A questão refere-se ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, que já foi objeto de análise por esta Sexta Turma em habeas corpus, inexistindo motivo hábil para nova deliberação. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

No mais, a nulidade do reconhecimento apenas seria possível caso comprovado prejuízo ao réu, de acordo com o princípio *pas de nullité sans grief*. Ademais, o reclamo resta afastado uma vez que o reconhecimento foi confirmado em Juízo pela vítima/testemunha.

Por fim, em que pesem as alegações da defesa acerca da ilegalidade da busca, a preliminar suscitada deve ser afastada. Com efeito, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade do policial militar ou guarda municipal realizar a prisão, porque nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante. No mais, a busca ocorreu durante a realização de diligência policial pela notícia de possível prática delituosa. A visualização do réu na rua, em lugar deserto e perto das dez horas da noite, somada com a tentativa de evasão do suspeito, ocasionaram a legítima suspeita de envolvimento do réu no delito, fato que comprova a legalidade dos atos perpetrados, que ocasionaram o encontro dos objetos/roupas no interior do veículo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão justificadas, pois de acordo com a lei: fundada suspeita (art. 244 do CPP). Policiais que apontaram de forma segura que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o acusado, que se encontrava sentado em uma guia num local conhecido como ponto de tráfico, adotou atitude evasiva, denotadora de fundada suspeita de que tivesse algo ilegal consigo. Desnecessidade, inclusive diante do encontro de drogas com ele e de ser desmentido quanto a estar

em outro local, que os policiais expusessem de forma mais elaborada a suspeita que os levaria à revista pessoal, que, bom que se diga, independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer momento, mesmo que não se trate de situação de flagrante (não há que se confundir busca pessoal com busca domiciliar). Expertise policial que merece ser prestigiada, assim como são os depoimentos dos agentes da lei. Prova segura da autoria e materialidade. Condenação bem aplicada, merecendo, a r. sentença, ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno inclusive no que tange à dosimetria, fixada com critério. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500559-92.2021.8.26.0535; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

No mérito, a ação penal é procedente.

Roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima.

A doutrina distingue duas espécies de roubo: roubo próprio, no qual a violência ou a grave ameaça é exercida antes da subtração da coisa, ou seja, a violência ou grave ameaça é exercida para que o agente subtraia a coisa material e ainda o roubo impróprio, quando o agente emprega a violência contra a pessoa ou a grave ameaça logo após subtraída a coisa.

O roubo próprio se encontra capitulado no "caput" do artigo 157 do Código Penal, e o roubo impróprio se encontra capitulado no parágrafo 1 do mesmo artigo.

Sobre o momento da consumação do delito de roubo, decidiu a 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com voto magistralmente relatado pelo eminente Desembargador Souza Nery, que este se dá no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente consegue retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo, estando portanto já consubstanciados todos os elementos da definição legal de roubo, independentemente do que venha a ocorrer na seqüência, ou seja, do grau de impertubabilidade da posse da res, da existência ou não de perseguição ou de sua intensidade, etc. (Apelação Criminal 990.09.067051-7, j. 13.08.2009).

Nesse sentido, o entendimento do STF:

"... o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência da posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do esforço imediato - seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão." (RE nº 102.490-9/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, in RT 677/428).

A materialidade do delito se encontra comprovada pelos autos de fls. 01, 09/14, 15/18 e 330.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amalhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Em local próximo ao do acusado foi encontrado o bem subtraído. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175). Erich).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado valer-se de todo o acervo probatório para decidir, desde que o faça motivadamente. A perícia não é o único elemento de prova apta para demonstrar o emprego da arma e a impossibilidade de sua realização, para comprovação da potencialidade lesiva do artefato, não tem o condão de, por si só, afastar a majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal..." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda que

momentânea reconhecimento da forma tentada impossibilidade. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

Roubo - Objetos subtraídos encontrados em poder do agente - Ônus de demonstrar a legitimidade da posse transferido a defesa - Inteligência do art. 156 do CPP. 131 - Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. RJDTACRIM VOL.6 PÁG. 140 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:- NOGUEIRA FILHO.

Ouvidos em juízo, o réu negou a prática dos delitos. Disse que trabalha de segunda a sexta-feira, mas o patrão queria que trabalhasse no sábado, sendo que pegou o carro de um amigo emprestado. Após o serviço, iria ao posto para beber com os colegas de trabalho, passou rápido pela casa da genitora, e depois foi pela estrada de terra, tendo em vista que sua habilitação estava vencida. Disse que quando estava chegando no posto foi abordado pela polícia, perto das sete horas, só que estava em movimento e não parado. Narrou que foi repetidamente agredido pelos policiais, e mediante ameaças de morte, acabou por confessar falsamente o crime. Em relação as camisas eram suas para o trabalho.

Em audiência, a vítima José, relatou o ocorrido informando que, entre seis e sete horas da noite, se encontrava trabalhando como controlador de acesso/vigia, quando chegaram três pessoas, de roupa escura, anunciando o assalto, e o renderam, sendo que todos portavam armas de fogo, do tipo pistola. Disse, ainda, que o os assaltantes ordenaram que ficasse quieto, sob ameaças de morte. Narrou que determinaram que abrisse a cancela, e assim eles subtraíram uma máquina e o amarraram, após evadindo-se. Durante o assalto, o qual durou cerca de três horas, após acionarem a máquina, o telefone da empresa tocou, e um representante alertou que a máquina estava em movimento, sendo que os assaltantes o ameaçaram e determinaram para dizer que estava tudo bem. Informou que o telefone também foi subtraído e não recuperado. Declarou que um dos assaltantes saiu com a máquina e outros dois permaneceram com o depoente, e apenas saíam quando a máquina chegasse em seu destino. Após a fuga, conseguiu soltar a mão e arrastou-se até a guarita, onde soltou os pés, e desceu até outra empresa para comunicar o ocorrido, o que aconteceu perto das dez da noite. Por fim, na Delegacia reconheceu o assaltante, pelas vestimentas. Em Juízo, afirmou certeza acerca de ser o réu o autor do delito.

E a pessoa de Eli, representante da pessoa jurídica, declarou que teve conhecimento acerca do assalto ao local, posto que a sobrinha verificou pelo sistema de rastreamento, a movimentação da máquina, entre oito e nove horas da noite. Disse, ainda, que com a polícia e o sistema de rastreamento foi possível localizar a máquina, a qual encontrava-se abandonada. Informou que seu irmão retornou a máquina ao imóvel e foram a Delegacia. Por fim, o vigia, o qual estava apavorado, narrou acerca do assalto e de ser amarrado.

Não há nos autos prova de que a vítima ou a testemunha conheciam o réu anteriormente ou que tivessem intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

É fundamental o depoimento da vítima/testemunha como prova para a condenação. De acordo com a doutrina:

"...Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime.

O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento

(RT, 269:136).

A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade.

Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido.

Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas.

Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil.

(...)

'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente'

(JTACrim 51:423).

'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes' (RT, 484:320).

No mesmo sentido: JTACrim, 60:314, 64:193, 73:79 e 22:354.(CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 150/151).

Sobre a importância do depoimento da vítima em casos de delitos contra o patrimônio, já decidiu a jurisprudência:

"(...) MÉRITO ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. (...)" (TJSP, Apl. Crim.0002294-84.2017.8.26.0210, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 05.02.2020).

ROUBO - Palavra da Vítima - Valor Probatante - "Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação"(TACRIM - Ap. nº 1.023.8013 - Limeira - 7ª Cam. - Rel. Juiz JOSÉ HABICE - j. 5.9.96, v.u.)

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (JUTACrim 94/341).

"Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, atualmente, o mais comum é o roubo, as palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxime se este não conhecia o réu" (RJDTACrim 15/148 - rel. Silva Pinto).

"Em delitos de roubo, de regra não testemunhados, as palavras das vítimas, se uniformes e coerentes, são elementos seguros de convencimento, principalmente se não há dúvidas no reconhecimento" (RJDTACrim 20/165 - rel. Abreu Machado).

PROVA - Crimes contra o patrimônio - Palavra da vítima - Valor:146 (a) - Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente. RJDTACRIM VOLUME 21 JANEIRO/MARÇO94 PÁG.:267 RELATOR:- WALTER SWENSSON.

O Policial Militar Ulsan declarou que receberam informações acerca do roubo e que os indivíduos já tinham se evadido do local. Narrou que a máquina subtraída possuía rastreador, o qual indicava a sua provável localização e para lá dirigiram-se.

Disse que patrulhando nas imediações da indicação do rastreador, verificaram um veículo parado, em ponto ermo, o qual ao avistar a viatura, demonstrou certo nervosismo, optando por realizar a abordagem. Indagado, o réu alegou que estaria aguardando contato de amigos, mas não soube precisar de onde vinha ou a trajetória. Em revista ao veículo, localizaram vestimentas escuras, as quais o réu não soube precisar a procedência. Em contato com a vítima, o qual era vigia/porteiro do local, ele relatou acerca do ocorrido e informou as características dos assaltantes, inclusive as roupas, as quais correspondiam com as vestimentas localizadas no veículo do réu. Novamente indagado, o réu confessou que faria parte do delito, sendo que teve a incumbência de levar os demais assaltantes a empresa e após a subtração iria pegar os indivíduos, estando os aguardando retornar. Por fim, ele informou que o proprietário do veículo também estaria envolvido. E, a máquina foi localizada em local próximo da abordagem.

E, o Policial Militar Rafael informou que foram comunicados acerca do roubo e dirigiram-se ao local onde indicava o sistema de rastreamento da máquina. Nas proximidades encontraram o veículo ocupado pelo réu, o qual ao avistar a viatura tentou evadir-se, mas foi abordado. Indagado, o réu inicialmente negou a participação, e em revista veicular localizaram duas blusas pretas. Narrou que, em contato com a vítima, esta relatou o ocorrido e informou as características, inclusive das vestes. Novamente indagado, o réu confirmou a participação no delito.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal;

Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

Por fim, a testemunha da defesa Hilda, genitora do réu, declarou que no dia dos fatos o réu saiu do trabalho e passou em sua casa, onde avisou que sairia com uma moça, tendo emprestado o carro de Charles, inclusive para visitar as filhas no domingo.

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

Em que pese a defesa apresentada, não é possível a absolvição, considerando a ameaça efetuada pelo réu, em concurso com terceiros ainda não identificados, inclusive com utilização de arma de fogo e restrição de liberdade, ao proceder a subtração do bem, restando configurado o roubo qualificado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA EM CONCURSO FORMAL. Condenação mantida. Réus confessos. Palavras do ofendido e de testemunha presencial.

Desclassificação para furto afastada. Grave ameaça comprovada pela simulação do porte de arma. Crime consumado. Inversão da posse. STJ, Súmula nº 582. Penas mantidas. Maus antecedentes comprovados. Concurso formal caracterizado. Regime

prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500056-43.2018.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

Há que se analisar que as declarações do réu são contrárias ao seu depoimento na Delegacia de Polícia, onde confirmou sua participação no delito (fls. 08).

Assim, a versão pueril do réu em juízo de que não praticou o roubo qualificado, restou isolada no conjunto probatório. Até porque, não provada. Não justificou a contento o que fazia no local no momento de sua prisão. É notório que no caso de invocação de alibi, inverte-se o ônus da prova, cabendo à parte que alegou demonstra-lo. De acordo com a doutrina:

"No terreno do processo penal há uma forma de defesa que é exclusiva e passou a ser conhecida como o 'alibi'.

Alibi, etimologicamente, significa em outra parte, em outro local. A princípio consistia uma exceção oferecida pelo acusado mediante a qual afirmava que, ao momento do crime, estaria em outro local, portanto, impossível sua participação. Com o decorrer do tempo ampliou-se seu significado, passando a representar toda alegação fática feita pelo acusado visando demonstrar a impossibilidade material de ter participado do crime.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constituiu uma exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração.

'Imperativa é a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta um alibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso' (JTACrim 54:204). Completando: JTACrim, 47:165, 33:334 E 22:77." (CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.18)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal. Autoria e Materialidade comprovadas. Palavra guarda municipal. Validade Precedentes. Ademais, o acusado foi encontrados na posse do objeto receptado. Incabível a alegação de insuficiência probatória. Alibi não comprovado. Inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal. Pena. Dosimetria. Reprimenda aplicada de forma adequada. Substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direito. Impossibilidade. Acusado reincidente em crime doloso. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação nº 0008542-14.2014.8.26.0229, da em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Silmar Fernandes, Data: 29/11/2018).

Estelionato - Vítima iludida e orientada a depositar valor na conta do réu para receber indenização judicial - Prova segura e coerente - Alibi do acusado fantasioso e não comprovado - Condenação mantida - Recurso provido em parte para adequação da pena, com reconhecimento da prescrição. (Apelação nº 0005053-20.2009.8.26.0495, da 11ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Alexandre Almeida, data: 01/12/2017).

PROVA - Invocação de alibi - Circunstância que resta indemonstrada - Formação de indício contra o réu - Entendimento:118 - Quem invoca alibi, para recusar a co-autoria, ou a participação em delito, não o provando, faz despontar indício de má justificação, a ser utilizado contra o réu. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 214 RELATOR: - SÉRGIO PITOMBO

Relativo a alegada coação para a confissão, restou improvada. E, como é sabido, o ônus de provar incumbe a quem faz a alegação.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO CONDENATÓRIO - VIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS - PROVA FIRME E CONSISTENTE DEMONSTRANDO A GUARDA DO ENTORPECENTE PELO RÉU - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA

DEFESA - RECURSO PROVIDO - DE OFÍCIO - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.

- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o réu como autor do crime de tráfico de drogas, imperiosa a reforma da sentença para condená-lo.
- Para a caracterização do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, crime de ação múltipla, basta que o agente guarde drogas, não exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.
- Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
- Impossível a absolvição do agente que alega ter praticado conduta antijurídica sob coação moral irresistível se não comprovada a alegada excludente de culpabilidade, sendo certo que, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus incumbirá à Defesa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.13.083392-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/0018, publicação da súmula em 22/01/2019)

Acerca das agressões, reforça-se o já delimitado as fls. 247: Ocorre que o laudo de fls. 54 (elaborado quando do flagrante), e o laudo de fls. 228 (elaborado cerca de quinze dias após a prisão), diferem apenas acerca do item: "Duas pequenas equimoses de cor vermelho/escuras, na região escapular direita. Uma medindo 10 x 3mm e a outra 15 x 3mm.", tendo em vista que a lesão supra-orbitária esquerda teria sido adquirida antes da prisão (informação do réu em ambos os laudos).

Desta forma, considerando a diferença de tempo entre a realização dos exames, somada com a informação de pequenas equimoses, que certamente foram produzidas no ambiente sabidamente violento do presídio, não restam caracterizadas as alegações de intensas e extensas agressões por parte dos policiais.

Relativo à qualificação (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), provada pelas testemunhas a existência da arma de fogo, não pode a qualificadora ser afastada pela simples falta de sua apreensão em poder do réu. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO. Recursos defensivos. Roubos majorados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, além de corrupção de menores, praticados em concurso formal e material. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defesa que não se insurgiu contra o encerramento da instrução criminal no momento oportuno. Preliminar afastada. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria dos delitos. Crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Delito formal. Comprovado o envolvimento de adolescente nas infrações penais praticadas pelos réus. Pretensão de afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo. Apreensão e perícia da arma que não são indispensáveis para a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Uso da arma de fogo comprovado pelas declarações das vítimas. Arma de fogo que possui potencial lesivo inerente à sua natureza. Condenação mantida. Dosimetria penal. Viável a redução da pena-base relativa ao corréu Leandro. Cabível o reconhecimento da continuidade delitiva específica entre os crimes de roubo. Aumento decorrente do concurso formal por violação a patrimônios jurídicos distintos afastado, a fim de evitar bis in idem. Precedentes do STJ. Penas redimensionadas. Regime inicial fechado mantido em razão do quantum das penas e da gravidade concreta dos delitos. Recursos parcialmente providos (TJSP - Apelação Criminal 0000982-34.2018.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)

APELAÇÃO. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da causa de aumento. Prova técnica substituída pela oral. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Reconhecimento de duas causas de aumento, uma das quais foi considerada como circunstância judicial. Alegação de imposição de dois aumentos sucessivos. Dosimetria mais benéfica. Ausência de modificação da quantidade de pena. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP - Apelação Criminal 1500108-23.2018.8.26.0616; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Apelação. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo em concurso formal. Sentença condenatória. Recursos das defesas. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento pessoal dos acusados. Relatos dos investigadores de polícia. Emprego de arma demonstrado. Desnecessidade de apreensão e perícia. Prova oral que indica a presença da causa de aumento. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias e consequências do delito. Roubo ocorrido em estabelecimento comercial com pluralidade de vítimas e bens subtraídos. Reconhecimento do concurso formal. Bis in idem configurado. Regime fechado mantido. Manutenção da custódia cautelar. Recurso provido para readequar as penas impostas. (TJSP - Apelação Criminal 1502946-56.2018.8.26.0577; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

ROUBO - Emprego de arma - Ausência de apreensão - Reconhecimento da qualificadora - Possibilidade.59 - A ausência de apreensão da arma empregada pelo agente quando da prática de roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial. RJDTACRIM VOLUME 10 ABRIL/JUNHO 1991 PÁGINA:117 RELATOR: GONZAGA FRANCESCHINI

ROUBO - Emprego de arma - Ausência de apreensão - Testemunho da vítima - Suficiência - Qualificadora - Configuração.74b - O testemunho da vítima e suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão. RJDTACRIM VOLUME 10 ABRIL/JUNHO 1991 PÁGINA:142 RELATOR:-MARREY NETO

Ainda, pelas provas e pelos depoimentos prestados pela vítima, restaram comprovadas as qualificadoras do concurso de pessoas e da privação de liberdade (art. 157, § 2º, II e V, do CP), ou seja, foi privada de sua liberdade, por tempo razoável, durante a prática do delito pelos réus.

ROUBO MAJORADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - NÃO ACOLHIMENTO - RESTRIÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DA OFENDIDA QUE RECONHECEU O RECORRENTE COMO O AUTOR DO ROUBO - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE EFETIVADA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO, SENDO ESTABELECIDO O REGIME INTERMEDIÁRIO, APLICANDO-SE A DETRAÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0014427-90.2016.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Assim, as provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

O conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar o roubo triplamente qualificado, no qual o réu e os terceiros, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, subtraíram os pertences.

ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e CORRUPÇÃO DE MENORES. Materialidade e autoria comprovadas quanto ao roubo e à corrupção de menores.

Causas de aumento do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas demonstradas - (...). (VOTO nº 18.921, Apelação Criminal nº 0012585-97.2016.8.26.0269, da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: DE PAULA SANTOS, Data: 27 de junho de 2019)

Assim sendo, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Em que pese ser o réu, na época dos fatos, tecnicamente primário, possui condenações anteriores transitadas em julgado (P. 0010607-39.2010.8.26.0320 - considerando a informação de fls. 45 - Data Fim Execução Real: 11/05/2016), sendo que deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo, delimitando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para um delito de roubo (artigo 157, do Código Penal).

Na segunda fase, verifica-se a inexistência de agravantes ou atenuantes a serem analisadas.

Ainda, por força do que dispõe o § 2º, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento, ensejando o roubo qualificado, acresço as penas em 3/8 (três oitavos), perfazendo em seis anos e cinco meses de reclusão e quinze dias-multa.

No mais, os termos do artigo 157, §2º-A, inciso I, aumento a pena de 2/3 (dois terços), totalizando a pena base em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Explico a dupla majoração. Evidentemente, situações mais graves devem assim ser tratadas. No caso dos autos, verifica-se que o delito foi cometido por pelo menos três agentes, e ainda contou com restrição de liberdade da vítima, por período razoável, mais o emprego de armas de fogo, além do alto valor do bem subtraído. Estas circunstâncias, em conjunto e concretamente, permitiram o sucesso da empreitada criminosa, incutindo maior temor na vítima e consumando o delito. "O disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, dá ao julgador discricionariedade e, com efeito, ninguém em sã consciência pode dizer que merece idêntica reprovação um crime de roubo com uma, com duas ou com três qualificadoras, em especial após a Lei nº 13.654/18" (TJSP; Apelação Criminal 1501112-62.2018.8.26.0530; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019)

Verifica-se a ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

O dia-multa é fixado no piso.

Regime de cumprimento da pena.

Superada a fixação da pena, com os fundamentos legais já expostos, de rigor a estipulação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, como exigido pelo artigo 59, inciso III do Código Penal.

Além da gravidade, só por si, o crime, que está num crescente assustador, colocando em polvorosa a comunidade ordeira de Americana, suas seqüelas para as vítimas, que prestaram depoimento na ausência dos réus, certamente atemorizadas ainda pelos fatos. A própria legislação atual, considerando a violência e a grave ameaça embutida no tipo, veda a substituição da pena privativa de liberdade pela

restritiva de direitos.

Não é por outro motivo que o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, na maioria de suas Câmaras e distinguindo corretamente as exigências para a fixação da pena e de regime, vinha elegendo o fechado como regra em se tratando de crime de roubo. Nestes autos, volto a anotar, circunstância alguma recomenda fixação de regime mais brando.

Assim o entendimento da doutrina:

"...pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do delito, que, no caso, vêm causando grande comoção social (MIRABETE, Julio Fabbrini, Execução Penal, 8a ed., Atlas, 1997, p. 255, texto e nota 6)".

"Não se pode porém olvidar que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-seá com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, consoante dispõe seu art. 33, § 3º.

Desse modo, num roubo, com emprego de arma, cometido por réu primário, ainda que a pena concreta não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, o juiz poderá determinar o cumprimento da pena em regime fechado. (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", Ed. Oliveira Mendes-APAMAGIS, 1997, p. 8)

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

REGIME PRISIONAL - Roubo qualificado - Imposição de regime fechado - Necessidade - Entendimento:68 - O regime fechado é o único compatível a ser imposto a condenado por crime de roubo qualificado, dada a frieza e desfaçatez de seu autor. RJDTACRIM - VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO 1992 PÁGINA 145 RELATOR:- JOSÉ HABICE

ROUBO - Regime Prisional Fechado - Necessidade Indeclinável - "É de primeira evidência que a perpetração de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que regem a convivência social. Pelo que, deve o Juiz sujeitar quem o pratica ao mais severo regime prisional. Demais, não é lícito dar de mão à circunstância de que a